

1501283-48.2020.8.26.0530
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Joice Sofiati Salgado
Comarca: Jardinópolis
Foro: Foro de Jardinópolis
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 03/08/2022
... a respeito do tema:

"Habeas Corpus - Tráfico ilícito de drogas - Revogação da custódia preventiva.
Inadmissibilidade O crime de tráfico é considerado um crime permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, dessa forma, a entrada dos policiais, sem mandado, na residência onde se encontrava o apelante tem seu fundamento no artigo 5º, inciso XI, da Constituição ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Jardinópolis[Foro do Processo]
2ª Vara
Praça Doutor Mário Lins, s/nº, Jardinópolis - SP - cep 14680-000

1501283-48.2020.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501283-48.2020.8.26.0530
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
TIAGO HENRIQUE FELIX

Vistos,

I. Relatório.

TIAGO HENRIQUE FELIX, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque, no dia, horário e local descritos na denúncia, durante período de calamidade pública, teria guardado e mantido em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 21,250g (vinte e um gramas e duzentos e cinquenta miligramas) da substância entorpecente cocaína, dividida, individualizada e acondicionada em 69 (sessenta e nove) microtubos de plástico roxo e de tamanho grande; 11,340g (onze gramas e trezentos e quarenta miligramas) da substância entorpecente popularmente conhecida como "crack", dividida e acondicionada em 104 (cento e quatro) invólucros de plástico incolor vedados com nós.

O acusado foi notificado às fls.101 e apresentou defesa preliminar (fls.114/115).

A denúncia foi recebida em 02 de março de 2021 (fls.119/120).

O acusado foi citado às fls.134.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

Nas alegações finais, a representante do Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação, com a consequente absolvição do réu, e, subsidiariamente, a concessão dos benefícios legais.

É o relatório.

II. Fundamentação.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls.24/27) pelo auto de prisão em flagrante (fls.12/14), pelos autos de exibição e apreensão (fls.28/29), pela imagem fotográfica (fls.30), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls.85/86), bem como a prova oral produzida.

Neste ponto, cumpre ressaltar que não se vislumbra qualquer vício na laudo pericial. Conforme consta do auto de exibição e apreensão, foi apreendida, além das cápsulas e substância sólida, quantidade de pó branco a granel. Foi constatada a existência de substância entorpecente em dois materiais, cuja existência fundamento a denúncia e é suficiente à caracterização do crime.

Passo a análise da autoria do crime.

O acusado, perante autoridade policial, declarou que, na data dos fatos, estava trocando a bomba de combustível do veículo de um colega (seu cliente) em frente à sua residência, quando uma viatura da Polícia Militar passou no local. Relatou que duas viaturas chegaram e dois policiais o abordaram, o indagando se possuía entorpecentes, o que negou. Informou que franqueou a entrada dos policiais em sua residência, onde nada de ilícito foi encontrado. Alegou que, no entanto, os policiais militares encontraram entorpecentes na residência ao lado da sua, a qual está abandonada. Negou que acompanhou as buscas e apreensões na casa abandonada. Esclareceu que mudou para aquela residência há três dias e que o dinheiro apreendido pelos policiais era oriundo do benefício "Auxílio Emergencial" que recebeu do governo. Por fim, negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos (fls.17/18). Em juízo, informou que possui 22 anos de idade, é amasiado e tem duas filhas. Relatou que estudou até o nono ano e que labora com serviços gerais, com registro em carteira. Declarou que já foi preso e que era usuário de "maconha" há sete anos. Aduziu que estava residindo no imóvel com sua esposa há dois dias. Em relação aos fatos, negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos. Salientou que estava trocando uma bomba de gasolina, em frente sua residência, quando os policiais chegaram e o indagaram de quem era a residência. Elucidou que, após dizer que a residência era sua, os policiais adentraram o local, sem sua autorização, e não o deixaram acompanhar as buscas na residência. Mencionou que os policiais disseram que, como ele não estava deixando eles entrar na residência, ele "iria ver". Esclareceu que não localizaram ilícitos na sua residência e que, em busca na casa ao lado, no alçapão, localizaram os entorpecentes, que foram levados para a residência dele. Acrescentou que os policiais o prenderam e o indagaram sobre a origem do dinheiro apreendido na residência, que respondeu ser proveniente do Auxílio Emergencial que recebia. Explicou que, na data dos fatos, estava com sua filha de dois anos de idade dormindo na residência. Manifestou que não havia entorpecentes entre os caixotes de papelão, bem como nos outros cômodos da residência. Contou que os policiais queriam o prejudicar porque já "aprontou" anteriormente e eles não gostam dele. Disse que o Auxílio Emergencial era recebido

pela intermediação da “Caixa Econômica Federal”, “PICPAY”, e “CAIXA TEM”. Narrou que havia sacado o dinheiro apreendido há três dias. Falou que, na data dos fatos, não possuía renda fixa e se sustentava através de bicos de mecânico e do dinheiro proveniente do aluguel da residência de seu genitor já falecido (R\$ 500,00).

O policial militar Olício dos Reis de Sá, em fase extrajudicial, relatou que, juntamente com seu parceiro de farda, receberam uma denúncia anônima sobre um indivíduo chamado Tiago, vulgo “capeta”, conhecido nos meios policiais, que estaria guardando entorpecentes em sua residência. Aduziu que foram ao local dos fatos, onde o réu estava sentado na calçada, em frente à residência e com o portão aberto. Mencionou que o réu foi abordado e que nada de ilícito foi encontrado, porém, estava muito apreensivo. Declarou que, diante de seu nervosismo e em razão da denúncia, a equipe passou a vistoriar o imóvel, com autorização do réu e, em um quarto com apenas algumas caixas de papelão, foi localizado um saco plástico que continha 17 (dezessete) “eppendorfs” de cor roxa, com substância análoga à cocaína. Asseverou que, em outro cômodo, onde o réu dormia, havia um colchão com a quantia de R\$350,00 (trezentos e cinquenta reais) e, ainda, em uma abertura que dá acesso à laje do imóvel, foi localizada uma sacola contendo uma porção a granel de um pó branco e 52 (cinquenta e dois) “eppendorfs” de cor roxa com substância análoga à cocaína. Informou que, também, foi apreendido outro saco plástico, contendo 104 (cento e quatro) porções de substância análoga a “crack”. Por fim, mencionou que o réu, ao ser indagado, negou o conhecimento sobre os entorpecentes apreendidos (fls.15). Em juízo, informou que receberam denúncia anônima de que o réu estaria traficando entorpecentes em sua residência. Relatou que foram ao local, onde encontraram o réu sentado na calçada e com a porta de sua residência aberta. Declarou que conversaram com o acusado e que, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Aduziu que, como o réu estava apreensivo e, como a denúncia versava sobre entorpecentes no interior da residência, o acusado franqueou a entrada dos policiais no local. Asseverou que, em um cômodo, entre vários caixotes, foram localizados cerca de 17 (dezessete) “eppendorfs”, de cor roxa, contendo cocaína. Salientou que seu parceiro de farda vasculhou outros cômodos, logrando êxito em localizar, em um quarto aos fundos, a quantia de R\$350,00 (trezentos e cinquenta reais) em cédulas fracionas. Manifestou que, em um alçapão, contendo marcas de uso frequente, foi localizada uma sacola, contendo 104 (cento e quatro) porções amareladas de substância semelhante a “crack”, mais uma porção à granel de pó branco e mais 52 (cinquenta e dois) “eppendorfs”, de cor roxa, com substância análoga à cocaína, idênticos aos localizados entre os caixotes. Elucidou que, ao ser indagado, o réu negou a propriedade dos entorpecentes, afirmando que estava residindo há dois dias na residência. Mencionou que o acusado não justificou a origem do dinheiro apreendido e que nunca o viu laborando. Esclareceu que o local era formado por duas residências germinadas, de forma que o réu residia em uma das residências e a outra estava desocupada. Contou que a laje era compartilhada entre as duas residências, mas os entorpecentes estavam localizados na laje no lado da residência do réu. Acrescentou que havia poucos móveis na residência, aparentando estar ocorrendo uma mudança na residência. Explicou que o réu já é conhecido nos meios policiais, há muito tempo, por tráfico de entorpecentes, receptação, inclusive quando era menor de idade.

O policial militar Rafael Eduardo Facioli, em fase extrajudicial, corroborou a versão apresentada pelo seu parceiro de farda. Em juízo, informou que, na data dos fatos, receberam denúncia anônima de que o réu, já conhecido nos meios policiais pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, estaria comercializando entorpecentes em frente à sua residência. Relatou que foram ao local, onde encontraram o réu, e, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Mencionou que o réu estava nervoso e, diante desta situação, os policiais o indagaram se possuía entorpecentes em sua residência, o que respondeu negativamente e autorizou que eles adentrassem o local. Declarou que o local era formado por duas residências germinadas, de forma que o réu residia em uma das residências e a outra estava desocupada e possuía pouca iluminação. Contou que a residência do réu possuía

poucos móveis, sendo aparente que estava ocorrendo uma mudança no local, não sabendo, todavia, se o réu estaria indo morar no local, ou se estaria saindo do imóvel. Narrou que, no quarto em que o réu alegou dormir, foi localizada a quantia de R\$350,00 (trezentos e cinquenta reais) em notas fracionadas. Aduziu que, ainda, em outro cômodo da residência, em meio a caixotes, foram localizados cerca de 20 (vinte) "ependorfs" de cocaína. Acrescentou que o entorpecente estava visível. Asseverou que localizaram um alçapão, onde encontraram o restante dos entorpecentes, tais sendo, pó análogo à cocaína e "crack". Manifestou que o alçapão era visível, estava aberto e possuía pegadas, sendo evidente que alguém subia no local. Afirmou que, embora a laje era compartilhada entre as duas residências, verificou de forma rápida, pois o bairro é muito hostil, que apenas na residência do acusado havia o acesso à laje e que os entorpecentes estavam localizados no lado da residência do réu. Explicou que havia um quarto com móveis ao fundo e que apenas o cômodo que possuía caixotes estava sem móveis. Contou que, a princípio, o réu alegou desconhecer os entorpecentes apreendidos e negou sua propriedade. Disse que o acusado confirmou que residia na residência. Narrou que o réu não disse a origem do dinheiro apreendido. Salientou que a denúncia versava diretamente sobre o acusado, sendo dito seu nome. Elucidou que o réu é conhecido nos meios policiais há anos, inclusive, quando era menor de idade.

Eis o teor da prova oral.

Tem-se que o réu negou a propriedade dos entorpecentes, todavia, não restam dúvidas quanto à sua posse.

Com efeito, os depoimentos dos policiais foram firmes, coerentes e harmônicos no sentido de afirmar que receberam denúncia de que o réu estaria praticando o tráfico de entorpecentes na em sua residência, onde, em busca pelo imóvel, foram localizados os entorpecentes apreendidos e quantia em dinheiro.

E, não há nos autos qualquer indício de que os policiais tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do acusado. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais militares.

Ora, o réu apenas afirmou ser vítima de falsa incriminação, alegação desprovida de qualquer substrato fático.

Aliás, neste ponto cumpre ressaltar que não se vislumbra qualquer ilegalidade por suposta violação de domicílio.

Extrai-se dos autos que o réu autorizou a entrada dos policiais no imóvel, o que foi por ele informado à Autoridade Policial (fls. 17). E, neste ponto, cumpre ressaltar que, embora o acusado tenha, em juízo, negado ter autorizado o ingresso no local - o que o faz no exercício de sua defesa, é certo que os policiais asseveraram que o réu autorizou a entrada no imóvel.

Certo, ainda, é que a casa é asilo inviolável do indivíduo, entretanto, não pode ser adotada como garantia de impunidade de crimes quando praticados em seu interior. Assim, em se tratando de flagrante delito, não é necessário mandado de busca e apreensão domiciliar, pois o próprio texto constitucional admite que se penetre na casa sem o consentimento do morador, em caso de crime e desastre.

Outro não é o posicionamento da Corte Bandeirante a respeito do tema:

"Habeas Corpus - Tráfico ilícito de drogas - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade O crime de tráfico é considerado um crime permanente, ou seja,

sua consumação se prolonga no tempo, dessa forma, a entrada dos policiais, sem mandado, na residência onde se encontrava o apelante tem seu fundamento no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não gerando, portanto, provas ilícitas - Outrossim, a efetiva localização dos entorpecentes no interior do imóvel, configura o estado de flagrância, o qual autoriza a prisão, a instauração do inquérito policial, bem como a justa causa para a ação penal - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal A eventual possibilidade de fixação de regime inicial mais brando ou eventuais benefícios que poderão ser concedidos, é matéria que foge desta seara de cognição sumária do "writ", visto que somente poderá ser enfrentada após a colheita da prova, onde todos os postulados constitucionais do paciente serão observados. E, portanto, somente poderá ser analisada após a realização da instrução processual - O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória - Ordem denegada"(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2254225-88.2019.8.26.0000; Relator (a): Freitas Filho;Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 5ª Vara Criminal;Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020).

Ademais, embora a laje, onde foram localizados alguns dos entorpecentes, seja compartilhada entre a residência do réu e a outra casa, que está desocupada, os policiais foram firmes ao afirmarem que havia marcas de uso no alçapão, no lado da residência do réu, bem como que os entorpecentes estavam localizados na laje em cima da residência dele, não na outra.

No caso, a grande quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas e o modo e local em que se deu a apreensão demonstram, à saciedade, que a droga se destinava ao consumo de terceiros.

Embora os policiais não tenham visto o réu entregando drogas a terceiros, tal fato não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal, vez que a figura típica capitulada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 trata-se de um tipo misto alternativo e tem como núcleos (...) ter em depósito (...) guardar, (...), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". Assim, para a caracterização do delito de tráfico, é suficiente que o agente traga consigo o entorpecente e os guarde- o que ficou sobejamente demonstrado nos autos -, pois a consumação não exige qualquer resultado, como a venda ou a entrega efetiva ao consumo.

Em casos tais já se decidiu:

"Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado" (TJSP - Ap. 187.915-3/2 - Rel. CRISTIANO KUNT - RT 727/478).

Por outro lado, alterando entendimento anteriormente adotado, não se vislumbra mais hipótese de reconhecimento da agravante da calamidade pública. Isso porque não há fato no caso em apreço que demonstre que o réu tenha se aproveitado da situação imposta pela pandemia do novo coronavírus para o cometimento do crime em tela.

Nesse sentido:

"[...] 1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX

FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. 2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021);

"Tráfico de drogas - mantidas as condenações - circunstâncias que denotam ciência dos acusados de que no veículo havia mais de nove quilogramas de maconha. Afastamento da preliminar de nulidade decorrente da ausência de resposta à acusação - a Defesa foi regularmente intimada para apresentar a defesa preliminar, não o fazendo - nova oportunidade foi aberta durante a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que arrolou as mesmas testemunhas contidas no rol do parquet, sem qualquer insurgência. Redução das básicas - possibilidade - "reprovação social" por "passagem pela Justiça", sem apontar eventual certidão de condenação definitiva. Afastamento da agravante relativa ao crime cometido durante estado de calamidade pública - Possibilidade - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito. Manutenção do regime prisional fechado - réus reincidentes - penas que excedem o quadriênio. Recursos parcialmente providos." (TJSP; Apelação Criminal 1513057-74.2021.8.26.0228; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021).

Destarte, comprovadas a materialidade e autoria delitivas, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, verifica-se que se trata de réu que não ostenta maus antecedentes. Por outro lado, considerando a quantidade e a natureza das drogas e seu maior potencial ofensivo (cocaína e "crack"), fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Não há agravantes a serem consideradas.

Faz-se presente a atenuante da menoridade relativa, de modo que se reduz a pena ao seu patamar mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Não há causas especiais de aumento e diminuição de pena a serem apreciadas.

Embora o réu seja primário, as circunstâncias concretas revelam não se estar diante de tráfico privilegiado. No total foram encontrados 69 (sessenta e nove) porções de cocaína, além de 104 (cento e quatro) porções de "crack", quantidade a princípio incompatível com a traficância esporádica e, em contrapartida, reveladora de uma dedicação à criminalidade. Além disso, embora a certidão juntada às fls. 140/141 não seja apta a configurar reincidência ou maus antecedentes, demonstra que o acusado se dedica a atividades criminosas.

Aliás, consoante pesquisa na sistema SAJ, foi o réu condenado nos autos do processo

nº 1500328-28.2020.8.26.0300, em primeira instância, por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Logo, as circunstâncias fáticas indicam não ser o réu traficante ocasional, mas habituado à atividade criminosa ("dedicação"). Desta feita, não faz jus à redução prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Em casos tais, já se decidiu:

"PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Pretendido afastamento do redutor pelo tráfico privilegiado, com imposição do regime fechado e afastamento das penas alternativas. Cabimento. 1) Pedido ministerial para o afastamento da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Acolhimento. Comprovadas autoria e materialidade do delito, os acusados recebiam R\$ 1.000,00 (mil reais) para ter em depósito mais de 500 (quinhentos) entorpecentes, indicando dedicação e habitualidade. Impedimento do benefício. Apesar da primariedade e dos bons antecedentes dos acusados, a quantidade e variedade (natureza) – cocaína e crack - da droga apreendida, visando claramente habitualidade da conduta espúria, com evidente dedicação àquela atividade, lhes retirava o direito da causa de diminuição referida. Pedido ministerial acolhido, com reflexos na dosimetria da pena. 2) Pedido ministerial para a fixação de regime fechado. Acolhimento. Regime obrigatório imposto por lei ainda vigente – Artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/1990 (com redação dada pela Lei nº 11.464/2007). Gravidade concreta que, de qualquer forma, impõe maior rigor na sanção. Inteligência dos artigos 5º, XLIII, da Constituição Federal e 33, §3º, do Código Penal. Pedido ministerial acolhido, com reflexos na dosimetria da pena. 3) Pedido ministerial para o afastamento das penas alternativas. Acolhimento. Incompatibilidade com o regime fechado, com evidência de insuficiência para reprovação e prevenção – artigo 44, I e III, do Código Penal. 4) Detração Penal. Irrelevante, no caso, o quantum da sanção para sua definição (regime), surge inaplicável a detração, para tanto, prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal. Eventual progressão, por outro lado, deverá ser avaliada no Juízo das Execuções, competente para tanto (artigo 66, III, "b", LEP). Provimento." (TJSP; Apelação 0000222-67.2017.8.26.0617; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/07/2018; Data de Registro: 06/07/2018, g.n.);

"EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito" (HC 122594/SP - Relatora Ministra Rosa Weber - J. 23.9.2014, g.n.).

Torno definitivo o quantum da pena acima.

A pena sendo superior a quatro anos, e não sendo socialmente recomendável, inviável cogitar-se da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito (artigo 44, II e § 3º do Código Penal), bem como da suspensão condicional da pena (artigo 77, I do Código Penal)

Considerando as circunstâncias do crime em comento, de extrema gravidade, o patamar da pena, a grande quantidade e natureza das drogas apreendidas ("crack" e cocaína), a primeira de maior poder de dependência e de maior risco à saúde, outro regime que não o mais gravoso será ineficaz para iniciar o processo de ressocialização do acusado. Destarte, fixa-se o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena.

Cabe invocar ensinamento do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 E ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR DA REPRIMENDA SUPERIOR A 4 ANOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. A quantidade e/ou natureza de drogas apreendidas constitui elemento idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, § 3º, do Código Penal - CP e em consonância com o entendimento desta Corte. (...) Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 414347 / SP 2017/0219134-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183), Data do Julgamento: 08/02/2018, Data da Publicação: 21/02/2018, T5 - QUINTA TURMA).

III. Dispositivo.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar TIAGO HENRIQUE FELIX, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão (regime inicial fechado) e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº. 11.343/06.

Condeno o acusado ao pagamento de custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

O réu respondeu solto ao processo, de modo que autorizo o recurso em liberdade.

Determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista a data dos fatos e o constante do documento de fls. 33, após o trânsito em julgado, expeça o necessário à restituição da quantia que foi apreendida ao réu ou pessoa da família por ele indicada por ocasião de sua intimação da sentença.

Transitada em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

P.I.C.

Jardinópolis, 03 de agosto de 2022.

Joice Sofiati Salgado
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA